

1500574-29.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/07/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piracicaba
Foro de Piracicaba
2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500574-29.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107416/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 24414253 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2107416 - DEL.POL.CHARQUEADA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS AMÉRICO DE DEUS

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 25 dias do mês de julho de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a). Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) LUCAS AMÉRICO DE DEUS, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Jose Valdeci dos Santos e Lincoln Tiago Amaro.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) comuns (Jose Valdeci e Lincoln)

pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza,

LUCAS AMERICO DE DEUS, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 19 de abril de 2022, por volta de 15h50min, na rua Jorge di Benê, na cidade de Charqueada, nesta Comarca, trazia consigo e guardava 12 porções de maconha, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A materialidade foi comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 14) e Laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 93/95).

A autoria, da mesma forma, é indubitosa.

Segundo se apurou, guardas civis receberam informações no sentido de que estava ocorrendo tráfico de drogas "no campo de futebol do bairro Gelsomina". Assim, dirigiram-se ao local, onde avistaram o denunciado sentado em um banco na companhia de um indivíduo identificado como Cauã.

Realizada a abordagem, em poder do denunciado e de Cauã nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em uma mochila que estava encostada no banco em que eles estavam sentados, foram localizadas 12 porções de maconha, a quantia de R\$ 200,00, em notas diversas, e uma carteira contendo os documentos pessoais do denunciado. Instado, informalmente, o denunciado alegou que "estava vendendo o mesmo, sendo que ele alegou que estava naquele local aguardando para receber mais um kit de entorpecentes para venda, o qual ele pagaria com o dinheiro que foi encontrado em sua mochila". Perante a autoridade policial, ele permaneceu em silêncio. Por sua vez, Cauã informou que é usuário de drogas e que o denunciado havia fornecido entorpecentes.

As circunstâncias da prisão, aliadas ao local da prisão, à apreensão de porções individualizadas e de dinheiro em espécie, bem como os depoimentos colhidos, evidenciam que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita ou à entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

José Valdeci dos Santos narrou "é guarda Civil e desempenha suas funções na cidade de Charqueada. Hoje, recebeu denúncia através da central da Guarda Civil, dando conta de que estava ocorrendo tráfico de entorpecentes no campo de futebol do bairro Gelsomina. Na companhia do GC Lincoln dirigiu-se até o local informado e lá encontrou dois indivíduos sentados em um banco no campo de futebol. Os indivíduos identificaram-se como sendo LUCAS AMÉRICO DE DEUS e CAUAN HENRIQUE FERNANDES. Em revista pessoal nada foi encontrado na posse dos mesmos. Próximo do banco onde estavam, encostada em uma árvore encontraram uma mochila, e em revista encontraram no interior da mesma uma carteira com os documentos pessoais de Lucas, R\$ 200,00 em notas diversas e uma embalagem plástica contendo 12 porções de maconha. Lucas admitiu que o entorpecente era seu e que estava vendendo o mesmo, sendo que ele alegou que estava naquele local aguardando para receber mais um kit de entorpecentes para venda, o qual ele pagaria com dinheiro que foi encontrado em sua mochila. Cauan alegou que é usuário de entorpecentes e que estava ali consumindo maconha na companhia de Lucas, sendo que era Lucas quem estava lhe fornecendo os entorpecentes que usava. Lucas confirmou a versão de Cauan. Diante dos fatos deu voz de prisão em flagrante à Lucas Américo de Deus, sendo ele conduzido a esta unidade policial, para onde também foi conduzido Cauan, o qual foi ouvido em assentada e liberado." (fls. 03/04).

Em juízo ratificou o depoimento prestado na fase policial. O réu confirmou que a

droga apreendida lhe pertencia e estava aguardando mais uma quantidade para comprar e iria pagar com o dinheiro apreendido.

Lincoln Tiago Amaro asseverou "É Guarda Civil e desempenha suas funções na cidade de Charqueada. Hoje, receberam denúncia através da central da Guarda Civil, dando conta deque estava ocorrendo tráfico de entorpecentes no campo de futebol do bairro Gelsomina. Na companhia do GC Valdeci dirigiu-se até o local informado e lá encontraram dois indivíduos no campo de futebol, sentados em um banco. Os indivíduos identificaram-se como sendo LUCAS AMÉRICO DE DEUS e CAUAN

HENRIQUEFERNANDES. Em revista pessoal nada foi encontrado na posse dos mesmos.

Encostado em uma árvore, próximo do banco onde estavam, encontraram uma mochila, e em revista encontraram no interior da mesma uma carteira com os documentos pessoais de Lucas, R\$ 200,00 em notas diversas e uma embalagem plástica contendo 12 porções de maconha. Lucas prontamente assumiu que o entorpecente era seu e que estava vendendo o mesmo, sendo que ele alegou que estava naquele local aguardando para receber mais um kit de entorpecentes para venda, o qual ele pagaria com o dinheiro que foi encontrado em sua mochila. Cauan alegou que é usuário de entorpecentes e que estava ali consumindo maconha na companhia de Lucas, sendo que era Lucas quem estava-lhe fornecendo os entorpecentes que usava.." (fls. 05).

Em juízo ratificou o depoimento prestado na fase policial. O réu confirmou que a droga apreendida era sua, inclusive estava usando-a com o menor. Não conhecia o réu ou o menor.

O declarante Cauan Henrique Fernandes disse "É usuário de entorpecentes. Hoje, dirigiu-se até um campo de futebol que fica próximo da praça do bairro Gelsomina na cidade de Charqueada. Lá estava um conhecido seu de prenome Lucas. Lucas convidou o depoente para juntos consumirem maconha. O depoente aceitou o convite. Lucas não falou para o depoente onde estava a droga. Antes que usassem o entorpecente foram abordados por uma viatura da Guarda Civil. Os guardas perguntaram sobre entorpecentes e o depoente disse que não sabia onde estava. Os Guardas Civis então revistaram uma mochila que estava próximo de Lucas e ali encontraram uma embalagem com algumas porções de maconha. Inicialmente Lucas disse que aos guardas que a mochila não era sua, contudo logo assumiu que era o proprietário da mesma. Não sabe se Lucas vende maconha naquele local. Hoje, aproximadamente dez minutos antes da chegada da Guarda Civil o depoente tinha fumado um cigarro de maconha junto com Lucas, sendo que foi Lucas quem forneceu o entorpecente que fumaram" (fls. 06). Perante a autoridade policial o réu permaneceu em silêncio" (fls. 07/08).

Interrogado em juízo, o réu alegou que a droga era para seu consumo. Havia doze "parangas", ou seja, doze porções. O dinheiro apreendido era do seu serviço. Os policiais chegaram e disseram que estava havendo consumo. Havia acabado de comprar a droga. Não disse aos guardas que iria vender a droga. Não disse que o dinheiro destinava-se a comprar mais kits de drogas. O dinheiro seria usado para pagar pensão alimentícia. Só usava maconha e não conseguia ficar sem a droga. Nada tem contra os guardas civis.

Diante do todo apurado há provas suficientes que demonstram que o réu foi autor do delito imputado na inicial.

A narrativa dos guardas civis foi firme e uníssona em confirmar que receberam informações acerca da prática do tráfico ilícito de drogas no local. Ao chegarem no endereço, avistaram o réu sentado em um banco na companhia de Cuan. Feita abordagem, em poder do réu e de Cauan nada de ilícito foi encontrado, porém encostada no banco foi localizada uma mochila contendo 12 porções de maconha e a quantia de R\$ 200,00, além de uma carteira contendo os documentos pessoais de Lucas. Informalmente, ele confessou o crime.

Pertinente salientar, que não há nada que invalide os depoimentos dos guardas civis, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados

em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso. Depreende-se que a droga pertencia ao réu, pois junto com ela foram localizados seus documentos pessoais. Não bastasse, Cauan confirmou que foi ao local para adquirir entorpecente do réu.

Salienta-se que a significativa quantidade de droga apreendida, modo de acondicionamento e localização de dinheiro não deixam dúvidas de que o entorpecente destinava-se à mercancia ilícita, razão pela qual o réu deverá ser condenado pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

Destarte, imperiosa a condenação do réu pelo delito em questão.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Na primeira-fase a pena deve ser fixada no mínimo legal, pois ausentes circunstâncias desfavoráveis.

Ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes e causas de aumento.

A quantidade de entorpecente apreendida e dinheiro apreendido demonstram que o réu se dedicava ao crime em questão. Ademais, as informações davam conta de que no local ocorria o tráfico ilícito de drogas, o que deixa claro que se tratava de uma conduta contumaz.

Tratando-se de delito assemelhado ao hediondo e tendo-se em conta a necessidade de se individualizar a pena para a adequada prevenção e reprovação, incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo o réu iniciar o desconto da pena no regime inicial fechado.

Destarte, requer seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos exatos termos da inicial.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente garantia da ordem pública, deverá ser indeferido apelo em liberdade.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Lucas Americo De Deus está sendo denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 63-65) no dia 19 de abril de 2022, por volta de 15h50, na rua Jorge di Benê, na cidade de Charqueada, nesta Comarca, Lucas Americo De Deus, qualificado a fls. 07/08, trazia consigo e guardava 12 porções de maconha, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, guardas civis receberam informações no sentido de que estava ocorrendo o tráfico de drogas "no campo de futebol do bairro Gelsomina". Assim, dirigiram-se ao local, onde avistaram o denunciado sentado em um banco na companhia de um indivíduo identificado como Cauan.

Realizada a abordagem, em poder do denunciado e de Cauã nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em uma mochila que estava encostada no banco em que eles estavam sentados, foram localizadas 12 porções de maconha, a quantia de R\$ 200,00, em notas diversas, e uma carteira contendo os documentos pessoais do denunciado. Interrogado em solo policial, o acusado permaneceu em silêncio.

Na delegacia o guarda municipal Jose Valdeci Dos Santos, disse que: "É guarda Civil e desempenha suas funções na cidade de Charqueada. Hoje, recebeu denúncia através da central da Guarda Civil dando conta de que estava ocorrendo tráfico de entorpecentes no campo de futebol do bairro Gelsomina. Na companhia do GC Lincoln dirigiu-se até o local informado e lá encontrou dois indivíduos sentados em um banco no campo de futebol. Os indivíduos identificaram-se como sendo LUCAS AMÉRICO DE DEUS e CAUAN HENRIQUE FERNANDES. Em revista pessoal nada foi encontrado na posse dos mesmos. Próximo do banco onde estavam, encostada em uma árvore encontraram uma mochila, e em revista encontraram no interior da mesma uma carteira com os documentos pessoais de Lucas, R\$ 200,00 em notas diversas e uma embalagem plástica

contendo 12 porções de maconha. Lucas admitiu que o entorpecente era seu e que estava vendendo o mesmo, sendo que ele alegou que estava naquele local aguardando para receber mais um kit de entorpecentes para venda, o qual ele pagaria com o dinheiro que foi encontrado em sua mochila. Cauan alegou que é usuário de entorpecentes e que estava ali consumindo maconha na companhia de Lucas, sendo que era Lucas quem estava lhe fornecendo os entorpecentes que usava. Lucas confirmou a versão de Cauan. Diante dos fatos deu voz de prisão em flagrante à Lucas Américo de Deus, sendo ele conduzido a esta unidade policial, para onde também foi conduzido Cauan, o qual foi ouvido em assentada e liberado". (fls.3)

Em seguida, ouvido o guarda municipal Lincoln Tiago Amaro, que trouxe aos autos as mesmas informações.

A testemunha Cauan Henrique Fernandes, ao contrário do que alegaram os guardas, relatou na delegacia o seguinte: "É usuário de entorpecentes. Hoje, dirigiu-se até um campo de futebol que fica próximo da praça do bairro Gelsomina na cidade de Charqueada. Lá estava um conhecido seu de prenome Lucas. Lucas convidou o depoente para juntos consumirem maconha. O depoente aceitou o convite. Lucas não falou para o depoente onde estava a droga. Antes que usassem o entorpecente foram abordados por uma viatura da Guarda Civil. Os guardas perguntaram sobre entorpecentes e o depoente disse que não sabia onde estava. Os Guardas Civis então revistaram uma mochila que estava próximo de Lucas e ali encontraram uma embalagem com algumas porções de maconha. Inicialmente Lucas disse que aos guardas que a mochila não era sua, contudo logo assumiu que era o proprietário da mesma. Não sabe se Lucas vende maconha naquele local. Hoje, aproximadamente dez minutos antes da chegada da Guarda Civil o depoente tinha fumado um cigarro de maconha junto com Lucas, sendo que foi Lucas quem forneceu o entorpecente que fumaram". (fl. 6)

Juntadas folhas de antecedentes e certidões de objeto e pé (fls. 32) que comprovam a primariedade do acusado.

Às fls. 43-45, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Citado (fls.75), o acusado manifestou interesse de ser defendido pela Defensoria Pública, que apresentou defesa prévia às fls. 79-81.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo laudo de fls. 93-95.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, ouvido o guarda Jose Valdeci Dos Santos. Receberam denúncia de tráfico no local. Foram até lá, localizaram Lucas e um colega. Lucas teria dito que estava traficando. Próximo a ele, localizaram as drogas. O local é um campo de futebol de areia. Lucas e o amigo estavam sentados em um banco. Somente os dois estavam no campo. Ambos foram revistados e nada localizaram com ambos. Perguntaram para Lucas, e ele teria confessado a traficância. Fizeram as buscas. Foi o depoente que a localizou, estava próxima a Lucas. Na bolsa havia uma boa quantia em dinheiro. A droga estava próxima, mas não na bolsa. Não sabe descrever o local, estava no local a parte, não estava escondida. Eram 12 porções de maconha. A outra pessoa falou que estava apenas usando drogas no local e que teria adquirido a droga de Lucas. No momento, o local era ponto de venda de drogas. Lucas disse que o dinheiro era dele e que estava esperando mais uma remessa de drogas para comprar. Não conhecia o réu.

b) Em seguida, ouvido o guarda Lincoln Tiago Amaro. O local onde Lucas estava era conhecido por tráfico e os moradores do bairro já tinham feito diversas denúncias. No dia, receberam uma denúncia de que havia duas pessoas no local. Ali, depararam-se com Lucas e seu amigo. Estavam parados, sentados em um banco próximo a uma praça e um campo de areia. Somente os dois estavam no local. Foram abordados e revistados. Nada de ilícito foi localizado. Indagado, Lucas disse que estava traficando e tinha mais R\$200,00 para comprar mais drogas. A traficância seria por conta de dívida de pensão alimentícia. Em buscas, localizaram algumas porções de maconha perto dele, não se recorda quantas. O dinheiro estava com Lucas. A droga estava a uma distância entre 1 metro e 1,5 metro dele. Se não se engana, a droga estava próximo a uma mochila, perto de uma árvore. Sobre a localização do dinheiro, estava com ele, e não na mochila. Confirmou que a droga era dele. O amigo disse que estava ali usando

droga junto com Lucas. Disse que era usuário e que já tinha sido internado. Ele não disse quem forneceu a droga. Disse que, na delegacia, Lucas disse que ele forneceu drogas para Cauan usar.

c) Por fim, interrogado o acusado Lucas Americo De Deus. Admitiu que a maconha era mesmo sua, para consumo. Estava com 12 porções. Elas estavam separada, fora da bolsa. A GM chegou e deu voz de prisão. Estava acompanhado de Cauan, estavam do lado, conversava com sua tia por telefone por vídeo quando a guarda chegou. Nesse momento, Cauan não estava sentado no mesmo banco. Primeiro, o réu foi abordado, pois estava perto da guia. Depois, Cauan foi abordado. Os policiais não localizaram nada com ele. Na sua bolsa estavam os R\$200,00, recebidos por um serviço que tinha feito. Os guardas primeiro chegaram e disseram que havia uma denúncia de tráfico. Quando acharam a porção, confirmou que era sua, para consumo. Tinha acabado de sair do serviço, estava com roupas de trabalho. Foi ao local, tinha acabado de comprar a droga, por isso ela ainda estava fora da bolsa. Não é verdade que disse ser traficante. Nisso, os guardas disseram que ele era traficante, mas ele negou. Na delegacia, disse que a droga era para o seu consumo, e lhe disseram que ele forneceu para Cauan. Mas ele estava fumando com Cauan, não estava vendendo. Não disse aos policiais que ia comprar mais droga com o dinheiro. Esse dinheiro era fruto do seu trabalho como pintor e seria usado para pagar a pensão, que estava atrasada. Usa maconha há um ano, depois que perdeu o pai e a mãe. Tem 31 anos, nunca foi preso, sequer quando adolescente.

- DA ILICITUDE PROBATÓRIA: INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL Inicialmente, deve ser reconhecida a ilicitude probatória, tendo em vista a atuação inconstitucional e ilegal da Guarda Municipal.

Conforme relatado nos autos, a guarda civil municipal recebeu denúncia anônima e rumou para o local dos fatos com o objetivo de investigá-la. Conforme relataram, ali chegando, avistaram o acusado e terceiro sentados em um banco. Abordaram-nos e, revistados, nada foi localizado. Não estavam usando drogas e não se encontravam em situação típica de tráfico (troca de objetos, por exemplo). Apenas estavam sentados em um banco localizado em um campo de futebol. Não havia que se falar, portanto, em flagrante próprio, o mesmo que autoriza qualquer um do povo a dar voz de prisão. Não bastasse, os guardas continuaram a atuação fora das suas atribuições, investigando as imediações e realizando buscas. Teriam, então, segundo contaram, localizado 12 porções de maconha – na delegacia, disseram que em uma mochila que pertenceria ao réu; na audiência, disseram que nas imediações. E ainda não pararam por aí. Entrevistaram as duas pessoas abordadas, interrogando-os extraoficialmente. A atuação da GCM em atividade de policiamento ostensivo e investigativo, por si só, é ilícita.

Dessa maneira, a busca que resultou na apreensão das drogas foi oriunda de atuação da Guarda Civil Municipal. Ocorre que, nos termos da Constituição Federal, art. 144, § 8º, a Guarda Municipal não tem competência para tanto. É no mesmo sentido a lição doutrinária (GASPARINI, Diógenes; As guardas municipais na constituição federal de 1988, Revista dos Tribunais. set./1991. v. 671 p. 46-53; SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638-9).

Por conseguinte, é inafastável a conclusão de que a apreensão dos entorpecentes, por guardas municipais, tal como se deu nos presentes autos, é medida ilícita, tornando imprestáveis, portanto, os elementos de prova daí decorrentes.

Em reforço, não há que se alegar que os guardas municipais teriam atuado legitimamente porquanto, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, seria facultado a qualquer do povo efetuar a prisão em flagrante. In casu, não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à abordagem e às buscas nos arredores e em mochila que sequer estavam na posse do réu, somente denúncia anônima; o averiguado, portanto, não estava em situação de flagrância. É o que entendeu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ocorrido nesta Comarca de Piracicaba:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexiste óbice à prisão em situação de flagrância, efetivada por guardas

municipais ou qualquer outra pessoa, não havendo falar, em tais casos, em ilicitude das provas daí decorrentes.

2. Na hipótese, entretanto, após denúncia anônima, guardas municipais abordaram o réu e, com ele não encontrando entorpecentes, seguiram até terreno localizado nas proximidades, onde foram apreendidos, além de maconha, 10 reais, um filme plástico utilizado para embalar a droga e documento relativo à execução criminal do réu.

3. Desempenhada atividade de investigação, deflagrada mediante denúncia anônima, que desborda da situação de flagrância, deve ser mantido o reconhecimento da invalidade das provas dela decorrentes. 4. Recurso especial improvido. (STJ - 6.^a T - Resp 1.854.065- min. Nefi Cordeiro - j. 02/06/2021 - p. DJe 08/06/2021)

Em síntese, atuando como “qualquer do povo”, os guardas municipais podem, única e exclusivamente, efetuar a custódia de algum cidadão que esteja em situação de flagrante próprio (CPP, art. 301), mas não podem efetuar a busca pessoal ou desenvolver atividades tendentes à obtenção de elementos de informação, sob pena de afronta ao disposto no art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, eis que, para esses fins, a despeito de estarem encarregados da segurança pública (CF, art. 144), não são considerados “autoridades policiais”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (STJ, Habeas corpus 545.162/SP, Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 4/2/2020).

Assim, tem-se que a apreensão das drogas, no caso sub examine, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Municipal. Por esse motivo, o auto de apreensão das drogas deverá ser desentranhado dos autos, eis que é inadmissível o seu ingresso no processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157). E, por via de consequência, o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico são provas ilícitas por derivação, não podendo servir para formação da convicção judicial, vale dizer, mostram-se incapazes para atestar a materialidade do delito imputado ao denunciado.

Desse modo, a absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, é medida que se impõe. - DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Superada a tese exposta acima, o caso é de improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Segundo relato dos guardas, foram localizadas 12 porções de maconha na mochila de Lucas ou nas imediações - as versões em solo policial e na audiência mudaram. Ainda segundo os mesmos guardas, Cauan lhes teria dito que Lucas era o seu fornecedor de entorpecentes. Lucas também teria confessado a traficância.

Todavia, em solo policial, única ocasião em que Cauan foi ouvido nos autos - por opção da acusação, que não o arrolou no rol de testemunhas -, Cauan desmentiu os guardas. Relatou que Lucas era seu conhecido e que usou a droga na companhia dele. Foi taxativo ao dizer que não sabia nada sobre Lucas ser traficante.

Eventual sentença de condenação, portanto, estaria embasada nas declarações dos guardas sobre o que teriam escutado de Cauan - que, segundo eles, disse que Lucas era traficante -, cuja veracidade não foi comprovada nem na delegacia, nem em sede de contraditório e ampla defesa. Cauan, na delegacia, desmentiu os guardas. Em juízo, não foi ouvido por escolha da acusação, que não o arrolou.

Assim, os depoimentos dos guardas, ainda mais quando não corroborados por prova que poderia facilmente ter sido produzida pela acusação, são elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7.^a Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7.^a Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos guardas; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas

condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

No mais, ainda que se entenda pela suficiência probatória, impõe-se reconhecer que os elementos de prova produzidos em juízo não são suficientes para a constatação do delito de tráfico de drogas, mas, sim, para a configuração do uso de entorpecentes (LD, art. 28), uma vez que não demonstrado, de maneira inequívoca, o intuito de comercialização da droga.

No caso em tela, foram localizadas com o réu somente 12 porções de maconha, quantidade condizente com o uso de entorpecentes.

Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam melhor enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas palavras da Eminente Relatora, "No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas científicas sobre o tema e o 'Estudo Técnico para Sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006', de autoria de Maria Tereza Uille Gomes, de 2014, disponível em www.politicassobredrogas.pr.gov.br, traz valiosas informações de pesquisas científicas realizadas no Brasil. Vejamos: 'Estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente esta espécie de droga, na forma de sal, em variação de 1 a 10 (um a dez) gramas/dia, com média de 3,8 gramas por dia (ACN Nassif Filho, SG Bettega, S Lunedo, JE Maestri, F Gortz- Repercussões otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista das Associação Médica Brasileira, 1999; 45(3): 237-41). Segundo o IC/PR, a média de uso de cocaína, na forma de crack, é de 15 pedras diárias e de acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio da parceria entre SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina 'pedra'. Desse modo, há uma subjetividade intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a informação técnica nº 023/2-13 SETEC/SR/DPF/RS (Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do RGS), constata que cada pedra de crack pode variar de 01 a 1,5 gramas. Segundo o estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia'. Ainda, no trabalho "Usuário de drogas ilícitas internados em hospitais psiquiátricos: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos", de Paulo Borini e outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52, mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína." (p. 8-9 do Acórdão)".

É justamente o caso narrado nestes autos, em que a quantidade de drogas apreendida do acusado não é excessiva, corroborando as declarações do acusado no sentido de que é usuário.

Isso posto, é necessário atentar-se ao fato de que a discricionariedade policial, consistente no poder de apontar se o indivíduo abordado é usuário ou traficante, deve ser contida em âmbito judicial. Como explica, a propósito, Luís Carlos Valois:

"A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra [guerra às drogas]. Do veredito das ruas poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais" (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 28).

Por isso, para conter eventuais abusos e evitar injustas condenações, é necessário demonstrar, de maneira inequívoca, que as drogas apreendidas em poder do acusado se destinavam à comercialização, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não tendo sido demonstrado o intuito de comercialização da droga, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça:

"PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo" (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020).

Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, mostrando-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. E, uma vez efetuada a desclassificação, exsurtem algumas consequências.

a) Absolvição por inconstitucionalidade do tipo

A primeira delas é a necessária absolvição, tendo em vista a inconstitucionalidade do referido tipo. Com efeito, o art. 28 da Lei de Drogas é inconstitucional por ferir o disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal. Isso porque é inquestionável que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: "Os direitos à intimidade e à vida privada instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a possibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]" (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344). Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora, um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve, a propósito, Nilo Batista: "O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais" (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do entorpecente.

Desse modo, fixada tal premissa, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereceriam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como

políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas. Isso posto, diante da alegação ora invocada, de rigor que seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, afastando-se a imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas, o que torna imperiosa a sua absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

b) Aplicação de sanção na forma do art. 28 da Lei de Drogas

Porém, rejeitada a pretensão de inconstitucionalidade, mas operada a desclassificação, é o caso de aplicação das sanções cominadas pelo art. 28 da Lei de Drogas.

- ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Pena-base

Na remota hipótese de condenação pela prática de tráfico de drogas, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior. Da mesma forma, o réu é primário e a quantidade de drogas não é exacerbada. Tais circunstâncias, portanto, recomendam a pena-base no patamar mínimo.

b) Segunda-fase: atenuantes

Ausente atenuantes e agravantes.

c) Aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da LD

No presente caso, é possível o reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da LD. Ora, estão presentes todos os requisitos do referido dispositivo, sendo certo que, conforme jurisprudência pacífica do STF, a quantidade e a natureza das drogas não é circunstância que, por si só, autoriza a denegação de aplicação do referido dispositivo (RHC 138715/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23.5.2017).

Ainda, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível o afastamento do privilégio com base apenas na quantidade ou na qualidade da droga apreendida:

Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado e da redução da fração de diminuição de pena por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas. (STJ. 5ª Turma. REsp 1.985.297-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 29/03/2022. Informativo 731)

Ressalte-se, por fim, que o réu tem 31 anos e nunca ostentou qualquer outra passagem policial, além de ter sido preso com pequena quantidade de maconha – entorpecente de menor potencial ofensivo –, sendo evidente que suas condições pessoais circunscrevem uma situação clássica na qual o privilégio deve ser reconhecido.

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, reconhecido o privilégio, de rigor a fixação do regime inicial aberto.

Ainda que não aplicado o redutor do art. 33, §4º, da LD, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDO (DETRAÇÃO E ART. 387, § 2º, DO CPP)

Além disso, considerando que o réu respondeu preso ao processo, impõe-se que o

tempo de prisão provisória seja declarado como tempo de pena já cumprida, efetuando-se, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a detração; é o que se extrai do referido dispositivo, assim como da Exposição de Motivos da Lei n. 12.736/2012 e da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 652.915/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

- SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Finalmente, reconhecido o privilégio, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque o Senado Federal, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52, X, da CF, editou a Resolução n. 05/2012, suspendendo a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A Resolução por conta do julgamento do Habeas Corpus 97.256/RS, em setembro de 2010, ocasião em que o STF, por seis votos a quatro, o STF decidiu que são inconstitucionais dispositivos da Lei n. 11.343/2006 que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas. Ainda que se discorde da conclusão alcançada pelo STF, o fato é que, com a edição da mencionada Resolução, pelo Senado Federal, restou afastado o fundamento formal-positivo para a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que suspensa a execução da lei, dotando a decisão do STF, tomada em sede de controle incidental, de efeitos erga omnes. Possível, pois, a aplicação de penas restritivas de direitos, porquanto presentes os requisitos do art. 44 do CP: a) a pena, ao final aplicada, não será superior a 4 anos; b) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; c) o réu não é reincidente em crime doloso; d) a medida mostra-se suficiente, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59.

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. Com efeito, de acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador “[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2). Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

LUCAS AMERICO DE DEUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 19 de abril de 2022, por volta de 15h50, na Rua Jorge di Benê, na cidade de Charqueada, nesta Comarca, trazia consigo e guardava 12 porções de maconha, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas civis receberam informações no sentido de que estava ocorrendo o tráfico de drogas “no campo de futebol do bairro Gelsomina”. Assim, dirigiram-se ao local, onde avistaram o réu sentado em um banco na companhia de um indivíduo identificado como Cauã.

Realizada a abordagem, em poder do réu e de Cauã nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em uma mochila que estava encostada no banco em que eles estavam sentados, foram localizadas 12 porções de maconha, a quantia de R\$ 200,00, em notas diversas, e uma carteira contendo os documentos pessoais do réu.

Instado, informalmente, o réu alegou que “estava vendendo o mesmo, sendo que ele alegou que estava naquele local aguardando para receber mais um kit de entorpecentes para venda, o qual ele pagaria com o dinheiro que foi encontrado em sua mochila”. Perante a autoridade policial, ele permaneceu em silêncio.

Por sua vez, Cauã informou que é usuário de drogas e que o réu havia fornecido

entorpecentes.

As circunstâncias da prisão, aliadas ao local da prisão, à apreensão de porções individualizadas e de dinheiro em espécie, bem como aos depoimentos colhidos, evidenciam que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita ou à entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

A denúncia foi oferecida (fls. 65), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 67/68). Notificado (fls. 75), o réu apresentou defesa prévia, na qual requereu a revogação da prisão preventiva e alegou inocência (fls. 79/81).

A denúncia foi recebida, designando-se a audiência (fls. 96/98). O réu foi citado (fls. 108).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestam.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da Preliminar

Pleiteia a Defesa, o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante do réu.

Não se verifica qualquer abuso ou ilegalidade na diligência efetuada pelos guardas municipais que abordaram réu em ponto de venda de drogas, após denúncia de que praticava o tráfico de drogas, encontrando nas proximidades o entorpecente e uma mochila com dinheiro.

Por fim, a Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: "Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força".

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, ao contrário do postulado pela Defesa, o réu foi abordado na guarda da droga apreendida, logo após denúncia, havendo flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal - CPP.[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.º 603.686/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021) Ante o exposto, não conheço o presente habeas corpus. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator. (STJ - HC: 676532 SP 2021/0199414-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

"O recurso comporta parcial provimento. No caso, quanto à prisão em flagrante realizada por guardas municipais, inexistiu ofensa aos alegados dispositivos de lei federal, pois o entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte consolidada no sentido de que, "apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão" (HC n. 286.546/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). Nesse sentido, confira-se ainda: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019) 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 525.772/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, na segunda fase da dosimetria, compensar integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão, fixando a pena definitiva do